

Voces: JUEZ ~ NOMBRAMIENTO DE JUEZ ~ PODER EJECUTIVO ~ FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO ~ PODER LEGISLATIVO ~ RECESO DEL PODER LEGISLATIVO ~ PRESIDENTE DE LA NACION ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ DECRETO NACIONAL

Título: El nombramiento de jueces por parte del poder ejecutivo durante el receso del poder legislativo

Autor: Goldaracena, Joaquín

Publicado en: La Ley Online;

Cita Online: AR/DOC/133/2016

El reciente decreto presidencial designando dos jueces para cubrir vacantes en el máximo tribunal, por parte del ejecutivo, amerita un escrutinio profundo, por cuanto se relaciona directamente a las funciones asignadas a dos de los poderes establecidos en la Constitución Nacional.

Efectivamente, mediante el Decreto 83/2015 [\(1\)](#), el ejecutivo nacional resolvió designar a dos personas de indudable trayectoria, como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ocupando así las vacantes provocadas por las renunciaciones de los Dres. Zaffaroni y Fayt. Para así decretar, considera varias circunstancias de hecho y de derecho [\(2\)](#), siendo el inciso 19 del artículo 99 de la Carta Magna, su análisis e interpretación, apoyado en antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema [\(3\)](#), el de mayor relevancia.

El citado inciso dispone que "El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura."

Ahora bien, considerando que dicha cláusula es una traducción del artículo II, sección 2a, cláusula 3a de la Constitución de los Estados Unidos [\(4\)](#), resulta oportuno y conveniente abordar el análisis de dicha norma, a la luz de innumerables dictámenes del Fisco General de aquella nación durante varias décadas, reportes del Servicio Congresional de Investigación, y en especial un reciente pronunciamiento de su Corte Suprema Federal de aquella nación. Efectivamente, en el caso de la Junta Nacional de Relaciones del trabajo del pasado año [\(5\)](#), a pesar de rechazar un nombramiento de un miembro de dicha organismo por parte del ejecutivo durante el receso del Senado norteamericano, consideró que en los términos de la mencionada cláusula, los nombramientos se pueden realizar en cualquier clase de receso -siempre y cuando sea prolongado-, y aún en casos en que la vacante se haya producido durante las sesiones ordinarias, pero que subsista al momento del receso.

Para así decidir, el tribunal supremo ponderó en primer término que la cláusula de nombramientos durante el receso del Congreso era un método subsidiario al método de nombramientos con acuerdo del Senado, y que también se encuentra previsto en el art. 99 inc. 4º de nuestra Carta Magna.

Según el mencionado tribunal, dicha cláusula tiene su origen en El Federalista [\(6\)](#) Nros. 67 y 76 ambos escritos por Alexander Hamilton. Así, el mencionado padre fundador, propone que en principio la potestad presidencial de designar funcionarios de alto rango se debería conferir conjuntamente al Presidente y al Senado. En tal sentido, Hamilton destaca que la necesidad de contar con la aprobación del Senado es una conveniente verificación sobre el espíritu de favoritismo sobre el presidente, y que precisamente sirve para prevenir el nombramiento por parte de éste, de personas no aptas para llenar esas vacantes tales como amigos y familiares. Sin embargo, como estaba previsto constitucionalmente que el Senado debería sesionar al menos una vez al año [\(7\)](#), dicho cuerpo no sesionaría de manera permanente, y sería materialmente imposible citar a todos los senadores de los estados distantes al distrito federal con el fin de realizar la correspondiente sesión de nombramiento. Por tales motivos, se debería habilitar al presidente a ejercer dicha función de forma exclusiva y con carácter temporal, para llenar sin demoras esas vacantes, mientras dure el receso de la Cámara Alta.

De esta manera, quedaba claro para el tribunal norteamericano, que existía desde aquel entonces, una pugna entre las facultades del ejecutivo para nombrar determinados funcionarios y la práctica de la Cámara alta de sesionar una vez al año, tal como lo previa el artículo I, sección 4, cláusula 2 de la Constitución de aquella nación.

Es dable destacar que según el ministro Breyer, quien escribió la opinión mayoritaria del tribunal, al momento de interpretar la cláusula en cuestión se debe ponderar principalmente la práctica regular y habitual

seguida por el gobierno federal, en tal supuesto (8). Especialmente porque en más de doscientos años de historia, nunca se había presentado ante aquel un caso en donde se tenga que someter a escrutinio dicha cláusula.

Pues bien, la primera cuestión que analizo el tribunal es el alcance del concepto receso -del senado- contenido en dicha cláusula. Así, comienza distinguiendo entre recesos inter sesiones, es decir aquel entre sesiones ordinarias anuales, e intra sesiones, es decir recesos durante la sesión regular. Según la visión del tribunal, el concepto de sesión incluye a todo tipo de receso, sea inter o intra sesión lo suficientemente extenso como para motivar el uso de aquella potestad exclusiva y excepcional, con el fin de asegurar el funcionamiento constante del gobierno federal, cuando el senado no se encuentra funcionando.

La segunda cuestión analizada es el alcance de la expresión que ocurra durante el receso (del Senado). Al respecto, el tribunal consideró que aunque el sentido literal no permitiría una interpretación amplia del significado, aplicando este concepto de ocurrencia al concepto de vacante, se podría arribar a dicha interpretación. Efectivamente, el tribunal cita, entre otros antecedentes, la opinión del Fiscal General William Wirt (9), aconsejando al presidente Monroe a adoptar una interpretación amplia de la expresión, la cual es más acorde con el espíritu y razón de la constitución. (10)

En tal sentido, el tribunal considera que la interpretación conjunta de las palabras vacante que ocurra, implica un estado continuo de un hecho o condición. Efectivamente, considera que el propósito de la cláusula respalda una interpretación amplia, cual es permitir al gobierno federal un correcto funcionamiento que facilite el cumplimiento de los deberes acordados constitucionalmente.

Así, aludiendo al dictamen del fiscal general mencionado, el tribunal propone un ejemplo que podría socavar tal función: en caso de que el presidente tomara conocimiento de una vacancia el último día de las sesiones, si se adoptara una interpretación restrictiva, se podría paralizar el funcionamiento del gobierno federal, llevando el mismo a la ruina. (11) Es que según dicho tribunal, el abuso por parte de ejecutivo de clausula no sería conveniente ya que la designación es provisional y está limitado en el tiempo, lo cual disminuye en alguna medida su capacidad de cumplir con la función encomendada.

En este punto cabe destacar el abuso en algunos nombramientos, que llevó al senado norteamericano a dictar en el año 1863 una ley limitando el pago de salarios a esta clase de oficiales (12) el cual fue morigerado varias décadas después y que fue recolectado por legislación más reciente. En la actualidad, el Código de los Estados Unidos (13) prevé que en los casos en que la vacante se haya producido durante el periodo de sesiones, el funcionario designado por la modalidad en cuestión, no puede percibir remuneración por parte del tesoro nacional, hasta que sea confirmado por el Senado. Ello, excepto que la vacante se haya producido dentro de los últimos 30 días del periodo de sesiones, o bien que dicha cámara haya rechazado una nominación, y la vacante se encuentre vigente al momento del receso, entre otras excepciones.

En suma, aunque ambas interpretaciones tienen sus consecuencias no deseadas, una interpretación restrictiva puede menoscabar una facultad conferida constitucionalmente al ejecutivo. Es por ello que se decidió adoptar la interpretación más amplia, la cual resulta más congruente con la razón y espíritu de la constitución norteamericana. (14)

En el caso de la Constitución Nacional, el artículo 99 inc. 19, coincidimos en primer término, que no puede dejar de analizarse sin el inciso 4 de dicho artículo. El mismo dispone que el Presidente. "Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto." De esta manera, siguiendo la télesis del tribunal norteamericano en el fallo mencionado, el cual ha analizado más de 200 años de opiniones y practicas relativas a la cláusula que dio origen a la presente en nuestra constitución, podemos concluir que la aplicación del proceso excepcional, siendo interpretado de la manera propuesta en juntamente con el inc. 4 del mismo artículo, alcanza para cubrir las vacantes como las que pretende cubrir el decreto del 15 de diciembre del año en curso. Aún para el caso de la vacante producida por la renuncia del Dr. Zaffaroni, es decir con anterioridad al receso. Pues resulta más coherente con la finalidad de la norma, sostener que la única limitación es la temporalidad de la designación, y

no la ocurrencia de la vacante a llenar.

Es evidente que el presente análisis de legitimidad resulta insuficiente sin el pertinente análisis político. Sin embargo, respondiendo este último a cuestiones y conceptos que se encuentran mayoritariamente fuera del espíritu de la ley, consideramos que aquel debe primar a fin de evitar acciones que puedan entorpecer el desempeño de las funciones del gobierno federal, en cumplimiento de sus objetivos claramente establecidos.

(1) B.O.R.A. N° 33.276 del 15 de diciembre de 2015.

(2) Circunstancias relativas al funcionamiento, como las relacionadas con las mayorías necesarias para adoptar las decisiones conforme el decreto ley 1258/58 y la ley 26.183 de Reducción del número de Jueces que la integran. Asimismo, la composición actual de tres miembros dificulta el desenvolvimiento, siendo urgente el nombramiento; Y por último, se fundamentó en el hecho de que la potestad en cuestión fue ejercida oportunamente por el ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

(3) Fallos 313:1232

(4) "El Presidente tendrá el derecho de cubrir todas las vacantes que ocurran durante el receso del Senado, extendiendo nombramientos provisionales que terminarán al final del siguiente período de sesiones." <http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html>

(5) National Labor Relations Board, Petitioner v. Noel Canning, et al. (2014) Docket nos 12-1281 Citations 573 U.S.

(6) The Federalist Papers, A. Hamilton, J. Madison & J. Jay. Random House Inc. 2000.

(7) Art. 1 sección 4.

(8) En tal sentido, el primer Presidente de los Estados Unidos, G. Washington ha nombrado durante el receso del Senado a J. Ellsworth como presidente del tribunal supremo, pero por su oposición al tratado de J. Jay, el Senado no ratificó su nombramiento, y terminó renunciando y siendo reemplazado por O. Ellsworth. El ex presidente D. Eisenhower a E. Warren como presidente de aquel tribunal y a Brennan y Stewart como jueces. En igual sentido, J. Madison, coautor del Federalista, es decir con amplio conocimiento en materia constitucional nombró a T. Gaillard para reemplazar un juez federal cuya vacante se produjo antes del receso. Hartnett, 26 Cardozo L. Rev., at 400-401 Por su parte, J. Bush y B. Obama han realizado decenas de nombramientos mediante esta modalidad durante sus presidencias. Henry B. Hogue; Richard S. Recess Appointments: Frequently Asked Questions. 11.03.2015 Congressional Research Service.

(9) Dicha opinión es también citada por nuestra Corte Suprema en el fallo que fundamenta el decreto 85/2015

(10) 1 Op. Atty. Gen. 631, 631-632 (1823)

(11) Op. Atty. Gen., at 632.

(12) Fordham Law Review, Volumen 81, 4a edición, artículo 12 "Taking Back What's Theirs: The Recess Appointments Clause, Pro Forma Sessions, and a Political Tug-of-War Alexander M. Wolf. (2013).

(13) 5 U.S.C. Section 5503(a)

(14) Op. Atty. Gen., at 632.